

RECURSO CÍVEL Nº 5060716-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

REPRESENTANTE LEGAL DO RECORRENTE: ALLANA CRISTINA LOPES DE OLIVEIRA (PAIS) (AUTOR)

RECORRENTE: LORENNALOPES DE OLIVEIRA DA SILVA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA O TRATAMENTO DE TRANSTORNO DE HIPERATIVIDADE E DÉFICIT DE ATENÇÃO. AUTOR MENOR IMPÚBERE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM CUSTO DO MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE EFICÁCIA CIENTÍFICA. PARECER DO NAT-JUS QUE APONTA OS EFEITOS DO CANNABIDIOL CONTRAINDICADOS PARA O DIAGNÓSTICO DA AUTORA. ESGOTAMENTO DAS OPÇÕES TERAPÊUTICAS NÃO DEMONSTRADA PELO AUTOR. SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Condene a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 10% do valor atualizado da causa, observados os parágrafos 2º e 3º do art. 98 do CPC. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5060716-93.2024.4.02.5101

510015744380 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5060716-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

REPRESENTANTE LEGAL DO RECORRENTE: ALLANA CRISTINA LOPES DE OLIVEIRA (PAIS) (AUTOR)

RECORRENTE: LORENNALOPES DE OLIVEIRA DA SILVA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus 200mg/mL no tratamento de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).

O Juízo de origem prolatou a decisão nos seguintes termos:

"Sem necessidade de relatório (Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, art. 38), passo diretamente à decisão.

Pelos laudos médicos é plenamente possível constatar que a parte autora realmente padece de enfermidade e precisa de tratamento. Portanto, a satisfação da pretensão atenderia um interesse legítimo, que não vem, todavia, a se configurar como direito.

O fato uma norma de caráter programático estar presente em Constituição analítica como a brasileira não é eficaz para dar origem a obrigações. Não que à existência de perigo para a vida fiquem alheios os poderes constituídos, pois a interesses jurídicos correspondem, no mínimo, deveres (não propriamente obrigações, como será visto abaixo), mas, ordinariamente o âmbito de atuação judicial é o dos direitos subjetivos obrigacionais, não os dos chamados direitos subjetivos públicos, excetuando-se, evidentemente, os casos de tutela coletiva.

Desde que a saúde é um bem jurídico, deve haver um titular deste mesmo bem, que, acreditamos, é a coletividade. A questão que se põe é da tutela de um direito que não surge como direito individual, porém como suscetível de gozo coletivo, tal como posto na Constituição e nas próprias leis que versam sobre a matéria.

Por outro lado, os critérios de conveniência e oportunidade do administrador público na distribuição dos recursos orçamentários disponíveis não podem, ordinariamente, ser objeto de análise pelo órgão judicial, sob pena de assunção de domínio do mérito administrativo por alguém não designado constitucionalmente para exercer tal atribuição.

De acordo com decisão do e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, invocada em decisão proferida pela ilustre magistrada então com jurisdição no 1º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro, e nos autos do processo 0006210-15.2011.4.02.5101, fls. 58/61:

À falta de elementos concretos que indiquem a injustificada negativa de prestação desse atendimento, e tudo levando a crer que a Autora nem sequer tentou seguir o trâmite regular de atendimento, não há como acolher a pretensão e substituir o Administrador Público, impondo o fornecimento específico e privilegiado da medicação a uma determinada paciente, em detrimento dos demais. A hipótese parece ser uma daquelas muitas submetidas ao Judiciário, em que se revela mais conveniente a obtenção de ordem judicial, com a imposição do fornecimento direto da medicação indicada pelo médico, do que o atendimento regular na unidade de saúde. Não deve, porém, o Poder Judiciário, em toda e qualquer demanda similar à presente, apenas embasado na solidariedade humana, interferir nas decisões administrativas que visam a garantir atendimento médico mais eficiente e de maior alcance, sob pena de cometer injustiças ainda mais graves e de violação ao princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal. (...)

No caso concreto, não é possível ao Judiciário, que não tem conhecimento sobre as prioridades, as enfermidades, a ordem administrativa em prol daqueles que também aguardam recursos para iniciar ou dar continuidade a tratamento de saúde, priorizar a autora, apenas sob a alegação de seu direito à saúde. Basta ler o artigo 196 da Constituição: o direito ali conferido busca adoção de políticas gerais, e respeito à isonomia.

Deferir a tutela é violar os princípios constitucionais da igualdade e da tripartição dos poderes. A saúde é dever a ser garantido de forma igualitária e mediante políticas sociais e econômicas, di-lo a Carta Maior. Mas não cabe ao Poder Judiciário suplantar a atuação administrativa e simplesmente determinar a entrega de medicamento específico, sujeito a controle e distribuição coordenada pelos órgãos públicos especializados. A improcedência do pedido é de rigor.¹

Vê-se logo que o interesse no recebimento de medicamentos ou insumos que digam respeito à saúde, do Estado e com recursos estatais, não é um direito, pelo menos no sentido individual que se lhe quer dar.

Vem de pouco tempo a noção da Constituição como criadora de direitos em nome de sua efetividade máxima. Tudo que se diz a respeito não convém que seja abordado agora, até pela profusão de material que tornaria inviável a tarefa. Em razão da ideia (ou ideologia) que é o conteúdo da pretensão de efetividade da Constituição muito têm sido deturpadas noções indispensáveis para o funcionamento de qualquer estrutura séria de salvaguarda de direitos subjetivos.

Pontes de Miranda e Orlando Gomes são os autores das seguintes passagens, abaixo transcritas:

"No sentido objetivo, o Direito é a regra a que devem obedecer atos humanos, para que produzam certos efeitos, ou que atribui certos efeitos a fatos ou atos, relevantes para a vida humana. O direito subjetivo é todo direito de que a regra jurídica objetiva dota os sujeitos de direito, conferindo-lhes projeção própria, atuação voluntária ou não. A regra jurídica que manda abrir a tantas horas os jardins públicos e fechá-los a certo momento da noite, ou conservá-los sempre abertos, para que todos por eles passem, possam sentar-se, descansar, é direito não-subjetivo. Os passantes, os freqüentadores e os que deles se servem para ler, trabalhar, como as mulheres que aproveitam a sombra das árvores para coser ou vigiar crianças, não têm direito subjetivo a isso, porque nem todos os direitos e posições jurídicas que se gozam são direitos subjetivos. A escola primária no Brasil é de direito objetivo; porém as crianças em idade escolar, ainda não têm direito subjetivo à escola. Nenhuma obrigação haveria da parte dos governantes, se os pais ou tutores reclamassem professores, prédios, bancos escolares. A diferença ressalta. O atraso da civilização é evidente."²

"Na conhecida definição de Ihering, direito é o interesse juridicamente protegido, mas, ainda que esse conceito estivesse imune a críticas cumpriria fazer a ressalva de que nem todo interesse legalmente protegido é direito.

Na dogmática moderna distingue-se interesse de direito, pelos fins a que se destinam as normas jurídicas. Conforme o esclarecimento de A. Von Tuhr, há disposições normativas que disciplinam a coexistência social para atribuir a cada indivíduo uma esfera de poder sujeita à sua vontade, e preceitos legais que estatuem deveres cuja observância é de interesse geral, pelo que é imposta e fiscalizada pelos órgãos do Estado. Quando os interesses do indivíduo se consubstanciam nas permitidas manifestações de sua vontade autônoma, apresentam-se como direitos. Se, no entanto, o interesse particular do indivíduo é tutelado pelo preceito estatuído no interesse geral, estará protegido de modo reflexo, mas não se caracteriza como um direito, porque o interessado não dispõe da faculdade de compelir quem o contraria a observar a norma, nem da faculdade de liberá-lo do seu dever. Enquanto das disposições que atribuem ao indivíduo uma esfera de poder derivam direitos subjetivos, das normas que estabelecem deveres a serem observados no

interesse geral, não nasce para o indivíduo direito algum, na acepção técnica do vocábulo. No entanto, seu interesse é protegido, porquanto o Estado pode exigir, de todos, obediência à norma que prescreve tais deveres."³

A doutrina estrangeira igualmente discorre sobre o ponto ora em exame:

"Não se deve, no entanto, acreditar que toda vontade de lei que obriga os órgãos do Estado a fazer ou não fazer alguma coisa seja de natureza tal que o particular a possa invocar. Há normas que regulam a atividade pública para consecução de um bem público, ou seja próprio de todos os cidadãos em conjunto, da coletividade (tal é o interesse de haver uma boa administração, um bom exército, boas fortificações; o interesse pela manutenção das estradas, e semelhantes). Dessas normas derivam direitos coletivos (ou direitos cívicos gerais), em tal maneira difusos sobre um número indeterminado de pessoas, que não se individualizam em nenhuma delas em particular: o indivíduo não os pode fazer valer, a menos que a lei lhe conceda converter-se em órgão da coletividade. O indivíduo como tal só dispõe de um direito para com o Estado ou outra administração pública no caso em que a lei reguladora da atividade pública haja tido em mira seu interesse pessoal, imediato, direto (conceitos de que adiante encontraremos aplicações)."⁴

A menos que possam ser impugnados os conceitos acima vistos por defeitos estritamente científicos que supostamente poderiam conter, fica definitivamente afastada a possibilidade de inferir diretamente de preceitos constitucionais o direito subjetivo em questão.

Admite-se que em certos casos de perigo real e iminente de perecimento da vida ou de perda de função vital de pessoa possa haver a intervenção judicial lastreada em direito de natureza diversa que então possa surgir (inclusive por efeito de relação contratual prévia, como é o caso das relações mantidas entre clientes e seguradoras de saúde). Isto não pode significar que sempre, em nome até mesmo da vida, deva o Estado necessariamente abdicar de todos os critérios advindos de seu próprio amadurecimento, notadamente daqueles critérios que mais estritamente tornam possível a administração de recursos públicos.

A vida que somente possa ser preservada por recursos extraordinários pode não ser mais hábil a fundamentar o sacrifício de tais recursos da coletividade, o que sempre é uma apreciação delicada. Estamos diante de questões a respeito das quais inegavelmente pode ser perigoso tentar imaginar previamente todas as possibilidades, sendo melhor simplesmente buscar apoio nas normas morais e no prudente arbítrio do juiz tanto que se apresentem os casos.

De modo geral, todavia, nos casos ordinários e não previstos em lei, é correto afirmar a inexistência de um direito e de uma correlata obrigação do Estado de fornecer todo e qualquer medicamento ou insumo de saúde a quem afirmar necessidade.

A questão também não pode ser posta em termos de simplificações tais como pertencerem ou não determinados medicamentos a listas de fornecimento do Sistema Único de Saúde. Tais listas expressam políticas de atendimento. Podem não ter a eficácia esperada relativamente aos medicamentos listados e sua efetiva potencialidade de tratamento. Isto não alterará, porém, em nada, o quadro jurídico a respeito.

Justamente para fazer frente a tais necessidades é que existem os programas governamentais e a própria possibilidade de alteração de tais programas pela pressão legítima da sociedade (se não satisfatórios as ações e o planejamento e atuação globais), ou por substituição dos dirigentes por eles responsáveis, por intermédio do voto e de outros meios democráticos. Na realidade, a tutela individual, em casos como o presente, tem pelo menos um efeito certo de natureza política: funciona como "válvula de escape" bastante eficaz do próprio sistema que, através do atendimento de pouquíssimos casos, obtém o esvaziamento de frentes políticas de atuação que tenham como fim uma mais eficiente gestão estatal da saúde pública.

Não se está aqui diante de um caso de perigo iminente onde a avaliação moral ou de algum direito natural da pessoa tenha de suplantar a noção de haver antes um interesse que cabe à Administração Pública gerir, até porque a intervenção estranha à Administração prejudica qualquer planejamento que antes já venha sendo observado no âmbito governamental, como é de se presumir que haja.

Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Sem custas e honorários.

Em caso de recurso, intime-se o Núcleo de Assessoria Técnica, para que já sejam remetidos os autos instruídos com o respectivo parecer, o qual não influenciaria o entendimento aqui exposto mas pode ser tido como relevante para o julgamento em 2º grau de jurisdição.

Oportunamente dê-se baixa e arquivem-se.

Rio de Janeiro, 08/11/2024"

Recorre a parte autora sob a alegação de que a decisão de primeiro não fundamentou o mérito de forma plena, que parte autora não tem condições de arcar com o ônus financeiro do tratamento e que este tratamento tem evidências científicas que justificam sua concessão em judicial.

É o breve relatório.

VOTO

A sentença não merece reforma.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora postula o fornecimento estatal de produto importado e sem registro na ANVISA (Evento 54 - Parecer NatJus).

Neste sentido, cumpre informar que o produto especificamente pleiteado **Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus 200mg/mL não possui registro** na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Dessa forma, **não está padronizado** em nenhuma lista oficial dispensados através do SUS (Componentes Básico, Estratégico e Especializado), no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro. Assim, considerando que não existe política pública de saúde para dispensação deste produto salienta-se que **não há atribuição exclusiva do estado nem do município em fornecê-lo.**

Quanto ao tema, é essencial partir do entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 1161):

"Tese: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS."

Ainda sobre o assunto, o STF se manifestou no **Tema 500** e fixou a seguinte tese:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Além disso, o NAT-JUS (54.1), em seu parecer, aponta que o medicamento pleiteando pela parte autora tem o potencial de agravar seu quadro de diagnóstico e que ainda não há indicação para tratamento para TDAH:

"Segundo posicionamento da Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP, não há evidências científicas suficientes que justifiquem o uso de nenhum dos derivados da cannabis no tratamento de doenças mentais. Em contrapartida, diversos estudos associam o uso e abuso de cannabis, bem como de outras substâncias psicoativas, ao desenvolvimento e agravamento de doenças mentais. O uso e abuso das substâncias psicoativas presentes na cannabis causam dependência química, podem desencadear quadros psiquiátricos e, ainda, piorar os sintomas de doenças mentais já diagnosticadas. O uso de cannabis também está associado à alteração basal de humor, à depressão, ao transtorno bipolar, aos transtornos de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e à ideação suicida.

Dessa forma, quanto à indicação do produto pleiteado, destaca-se que até o momento não há registrado no Brasil medicamento de Canabidiol com indicação para o tratamento de transtorno do espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade"

Dessa forma, a sentença embora não tenha discorrido sobre o quadro fático do processo, não deve ser alterada na sua conclusão, vez que não cabe ao Poder Judiciário conceder medicamentos experimentais com base na simples preferência do jurisdicionado ou de seus representantes, sobretudo aqueles medicamentos com evidências científicas que possam estar contraindicadas.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 10% do valor atualizado da causa, observados os parágrafos 2º e 3º do art. 98 do CPC. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

3. Gomes, Orlando. Introdução ao direito civil. 6ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 1979, p. 142 e 143.
4. Chiovenda, Giuseppe, Instituições de Direito Processual Civil, tradução da 2ª edição italiana, Saraiva, 1969, p. 7.